

1505439-64.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... foi apreendido pela prática do delito de tráfico anteriormente. Quanto ao adolescente Anderson tem conhecimento de que ele e Otávio se dedicam ao tráfico de droga, como ele mesmo afirmou, porém é a primeira vez que o apreende. (fls. 7/8) Leandro Fogo disse que não presenciou os fatos descritos pela denúncia. Conhece o acusado há mais de sete anos e sabe que ele é barbeiro, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505439-64.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505439-64.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FERNANDO LUIZ PRETOSE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

FERNANDO LUIZ PRETOSE foi denunciado e está sendo processado, pois no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 05h40min, na rua Mário Jacinto, nº100 e na avenida Suécia, Jd. Santa Teresinha, no Município e Comarca de Mogi Guaçu, agindo em concurso e unidade de desígnios com os adolescentes infratores Otávio Marques de Oliveira e Anderson Mariano Gustavo dos Santos, nas imediações de locais de trabalho coletivo, de entidades educacionais e de saúde, afora beneficentes ou assistenciais, tinha em depósito, guardava e trazia consigo, para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 1.678 (mil, seiscentas e setenta e oito) porções de cocaína em pó, pesando cerca de 567,93g (quinhentos e sessenta e sete gramas), embaladas em frascos plásticos, droga, conforme faz certo o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 76/78.

A denúncia foi recebida aos 26 de outubro de 2021, o acusado foi citado a fls. 173 e apresentou defesa prévia (fls. 113/115).

Durante a fase policial, foram ouvidas testemunhas, com o interrogatório do acusado ao final.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, condenando o acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a nulidade da prova produzida, decorrente do ilegal ingresso no local de trabalho do acusado. No caso de condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal e a incidência da atenuante da confissão espontânea. Pretende o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, III da lei antidrogas, pois o acusado guardava a droga, e não a comercializava em seu estabelecimento. Pretende, ainda, o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da lei antidrogas, pois o acusado não conhecia os adolescentes. Sustenta que deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, pois se trata de fato isolado na vida do acusado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, anoto que o ingresso no local de trabalho do acusado, pelos policiais militares, não padece de mácula de nenhuma natureza.

A esse respeito, mesmo contra a vontade dele, nas condições comprovadas nos autos, os policiais militares estavam legitimados a ingressar no local, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616, fixou a possibilidade de realização do varejamento domiciliar forçado pelos agentes públicos, sem mandado judicial, se “amparado em fundadas razões” para tanto, como se colhe da ementa daquele precedente:

Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. (...) 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

No caso dos autos, mesmo que sem a concordância do agente, estavam bem delineadas as fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos em sua residência, pois os adolescentes abordados na posse de porções de drogas indicaram que, no local, eram guardadas mais porções de cocaína, de modo que a busca domiciliar mostrava-se necessária para a apreensão de mais porções de cocaína, como de fato ocorreu. Ainda, há que se pontuar que o policial militar Flávio afirmou que o acusado autorizou o ingresso dos policiais e a busca pelo local, o que confirma a conclusão anteriormente exposta.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/24); pelo auto de constatação preliminar de substância tóxica (fls. 25); pelo laudo pericial do local (fls. 79/84); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 76/78), documentos de fls. 125/129 e por toda prova oral colhida em juízo.

O policial militar FLÁVIO AUGUSTO GARCIA POZZER disse que estava em patrulhamento pela Avenida Suécia e se deparou com os adolescentes Otávio e Anderson, já conhecidos pela prática de atos infracionais. Apreenderam pinos de cocaína com ambos e valor em dinheiro, além de indicarem local onde havia outros 4 pinos. Os adolescentes mencionaram que no salão também havia drogas. Disse que o acusado estava dormindo no local e, sob a cadeira usada para lavagem do cabelo, apreendeu

mais de 1.600 pinos de cocaína. O acusado teria dito que lhe pediram para guardar as drogas, mas não declinou nomes. Disse que a porta do estabelecimento estava parcialmente aberta e autorizou o ingresso. Não conhecia o acusado. Na fase policial, ALAN CRISTIANO RAYMUNDO, policial militar, disse que realizava patrulhamento, quando ao passar pela Avenida Suécia, local onde já tinha conhecimento de que os adolescentes infratores Otávio e Anderson permaneciam realizando o tráfico de drogas. Ao avista-los percebeu quando escondiam um embrulho em um terreno baldio; ambos foram abordados e no embrulho foram encontrados 24 pinos de cocaína, de cor preta, além de um mil duzentos e dezesseis reais em dinheiro. Anderson ao ser indagado, informou que havia mais quatro pinos na grade de um muro ali próximo e mais droga no salão de cabeleireiro do acusado Fernando. Deslocaram-se ao salão, que estava com a porta aberta e Fernando os atendeu, autorizando a entrada. Realizaram busca no salão e, sob o lavatório de cabelos, o depoente encontrou, dentro de duas sacolas, grande quantidade de pinos de cocaína, também na cor preta, totalizando aproximadamente um mil seiscentos e cinquenta pinos de cocaína. Ao ser indagado a respeito da droga encontrada, o acusado disse que só estava guardando a droga, mas não informando para quem. Disse que o depoente tem conhecimento de que o adolescente Otávio já foi apreendido pela prática do delito de tráfico anteriormente. Quanto ao adolescente Anderson tem conhecimento de que ele e Otávio se dedicam ao tráfico de droga, como ele mesmo afirmou, porém é a primeira vez que o apreende. (fls. 7/8)

Leandro Fogo disse que não presenciou os fatos descritos pela denúncia. Conhece o acusado há mais de sete anos e sabe que ele é barbeiro, além de trabalhar como servente. Nunca presenciou que o acusado costumasse guardar objetos no salão. Jean Kelvin dos Santos disse que é amigo do acusado e o conhece há muitos anos. Sabe que ele trabalha como barbeiro. Frequentava o estabelecimento e não se recorda dos adolescentes Anderson e Otávio. Nunca presenciou movimentação estranha no salão onde o acusado atendia.

Em solo policial, FERNANDO LUIZ PRESTOSE alega que não sabia que havia droga no seu salão de cabeleireiro. Disse que estava dormindo no salão porque sua casa está em reforma e não estava podendo ficar lá. Além disso, falou que uma pessoa desconhecida do interrogando pediu para que guardasse duas sacolas e o depoente sem saber o que nelas havia, guardou-as. Disse que hoje estava dormindo quando os policiais o acordaram e entraram no seu salão de cabeleireiro. Quando acordou os policiais já estavam dentro do seu salão de cabeleireiro e só soube que havia droga dentro das sacolas ali deixadas por pessoa desconhecida do interrogando. O acusado disse que não possuiu passagem policial anterior. Por fim, quer salientar que não conhece os adolescentes Otávio e Anderson. (fls. 11)

Em juízo, o acusado disse que "um rapaz levou três vezes as sacolas e pagou R\$ 300,00" ao interrogando. Disse que a porta do estabelecimento estava destrancada, mas totalmente abaixada. Não conhece os menores e eles não tinham envolvimento com as drogas apreendidas em seu estabelecimento, sendo que as porções de cocaína não foram deixadas no local por nenhum dos menores. Não saber dizer se os adolescentes indicaram aos policiais a existência da droga no salão. Sabia que havia droga no interior das sacolas, mas desconhecia a quantidade e natureza do entorpecente. Não conhecia os policiais militares.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais militares é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, além da confissão do acusado, na presente data.

Nesse sentir, o próprio acusado confessou que guardava a droga, confirmando que

recebeu R\$ 300,00 para a guarda do material, sendo inquestionável que sua conduta se subsume à previsão do artigo 33, caput, da lei n. 11.343/06.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava quantidade expressiva de droga fracionada, deve ser dada como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos policiais militares, na medida em que o próprio acusado disse que não conhecia e nada tinha contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime a ela.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, levando em conta a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de um mil e seiscientos invólucros), a pena privativa de liberdade deve ser fixada acima do mínimo legal, em obediência ao disposto no artigo 42 da lei n. 11.343/06, resultando em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes, mas incide a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena em 1/6, do que resulta pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de fls.79/84 revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existem estabelecimentos de ensino e locais de trabalho coletivo, como a empresa SITI, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas.

Aliás, a lei não exige que o estabelecimento de ensino seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Deve, ainda, ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI,

da lei n. 11.343/06, na medida em que o policial militar Flávio Pozzer, nesta data, confirmou que os adolescentes indicaram a existência de drogas no salão de cabeleireiro do acusado, razão pela qual para lá rumaram.

Tal não bastasse, os policiais militares afirmaram que as porções apreendidas na posse dos adolescentes eram idênticas às apreendidas no salão do acusado, o que corrobora a conclusão de que ele envolveu os adolescentes na prática do tráfico de drogas.

Por esses fundamentos, majoro a pena em 1/5, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

Inviável a incidência da causa de diminuição da pena previsto no artigo 33, § 4º, da lei antidrogas, pois aquele que recebe quantidade expressiva de drogas para guarda não pode ser tratado como traficante eventual, mas deve receber o tratamento daquele que vende droga de maneira farta.

Aliás, os Tribunais Superiores reconhecem que a expressiva quantidade apreendida é fator idôneo para impedir a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que demonstra que o agente, para ter acesso à droga, incorporou-se à organização criminosa, valendo destacar, a esse respeito, do Supremo Tribunal Federal, o HC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013, e do Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013, bem como, ainda, os seguintes precedentes:

VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO. Quinta Turma. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020).

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa" (STJ, HC 350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28-4-2016).

"5. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação à atividade criminosa" (STJ, HC 352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 28-6-2016).

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, em razão da grande quantidade de droga apreendida, o que permite a aplicação da regra prevista no artigo 33, § 3º, da lei n. 11.343/06.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO FERNANDO LUIZ PRESTOSE à pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06

O acusado respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 24 de janeiro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA